

1500027-07.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot\\_tjsp\\_jus\\_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EQgWpZFfSrJPkMPRHtJjZBsBoewmz0qk733U6czmxHp09Q?e=Pc8gRR)

EQgWpZFfSrJPkMPRHtJjZBsBoewmz0qk733U6czmxHp09Q?e=Pc8gRR

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500027-07.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000010

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005714/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22315181 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 128/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2005714 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO ADRIANO DA SILVA

Em 01 de junho de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Oscar de Oliveira Junior OAB 421053/SP, Advogado constituído neste ato, ora defendendo o acusado CAIO ADRIANO DA SILVA; o acusado referido; e as testemunhas Guilherme Ribeiro Lobo e Diego Aparecido Almeida Cornachin, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Em seguida, o Defensor requereu que fosse realizada perícia na roda do veículo e a MM Juíza indeferiu o pedido por não vislumbrar relevância para o deslinde do feito, conforme gravação que segue. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. CAIO ADRIANO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022. (p. 137-138) e o réu foi citado (p. 174). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério

Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu a absolvição, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias e laudo pericial, além da prova oral colhida na fase instrutória. A autoria é certa. Interrogado em juízo, o acusado confirmou a dispensa do invólucro com cocaína, que alegou se destinar ao seu consumo, e disse que assim agiu após os policiais terem efetuado um disparo contra o pneu do carro que conduzia. Afirmou, outrossim, que havia uma porção de maconha no veículo. Os policiais militares narraram, em suma, que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu na condução de um veículo. Ele se assustou ao ver a viatura, arremessou um invólucro pela janela e, após breve tentativa de fuga, foi abordado. No veículo havia uma pequena porção de maconha, que o réu alegou se destinar ao seu consumo. No invólucro por ele arremessado havia cocaína e o réu admitiu que parte dela seria vendida e parte consumida por ele. O acusado era conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico. A despeito das alegações defensivas, as provas são suficientes para comprovação do crime em comento. Ouvido em solo policial, o réu também admitiu ter arremessado a cocaína pela janela do veículo e disse que parte dela se destinava à venda (pg. 10). Os policiais afirmaram em juízo ter presenciado a dispensa do invólucro pelo acusado, que, como já mencionado, admitiu, tanto em solo policial quanto em juízo, ter arremessado a droga. Na fase inquisitiva ele também relatou que parte deste entorpecente se destinava à venda e em juízo alegou que foi agredido naquela repartição, o que não encontra amparo no documento de pg. 73. Os policiais apresentaram narrativas harmônicas a respeito dos fatos e não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). O fato do acusado não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para

essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739. Destaque-se, aliás, que, além da considerável quantidade de cocaína apreendida, o réu foi abordado com a droga em cidade diversa da qual residia e não comprovou o exercício de atividade lícita. Cumpre observar, outrossim, que o nobre causídico estava presente na audiência de custódia, na qual o réu alegou que os policiais haviam atirado no pneu do seu carro, mas não postulou nenhuma diligência à D. Autoridade Policial ou no curso do processo, deixando para fazê-lo apenas após o término da instrução. De qualquer modo, a diligência não se mostrou necessária ao deslinde do feito, até porque a posse (e dispensa) da cocaína foi admitida pelo réu e os policiais, notadamente Guilherme, relataram tentativa de fuga pelo acusado. Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos seguros a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolução - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)." Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado. Procedente a ação penal, passo a dosar as penas. Nesta primeira fase, a pena-base deve ser majorada, pois o réu ostenta maus antecedentes também pelo crime de tráfico (pg. 58), pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 59/60) e a descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, e considerando que reincidência é específica em relação a um dos crimes pelos quais foi definitivamente condenado, majoro a reprimenda de 1/3 para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do acusado. Tendo em vista que o réu é reincidente e o quantum da pena corporal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Não há se falar em desproporcionalidade ou "bis in idem" entre o reconhecimento da reincidência na segunda fase e o afastamento da causa de diminuição em comento, como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em bis in idem na utilização da reincidência do paciente na segunda fase de fixação da pena - para fins de agravamento da reprimenda -, e na terceira etapa da dosimetria - impossibilitando a aplicação da causa de redução de pena prevista no art.33, §4º, da Lei no 11.343/06 -, por haver expressa previsão legal para a ponderação dessa mesma circunstância nos dois momentos de fixação da pena, permitindo-se chegar à reprimenda mais adequada e suficiente para a prevenção do delito. 2. Habeas corpus denegado" (STJ - HC 188.699/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADODOTJ/CE), SEXTATURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 18/04/2011). Arbitro o dia-multa em seu valor mínimo, ante a ausência de comprovação de que o réu possa arcar com valor superior. Por fim, a despeito das

alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em

vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu CAIO ADRIANO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 dias-multa, no mínimo legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. O réu respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos bens apreendidos. Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e archive-se. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e Defensor informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

#### TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: CAIO ADRIANO DA SILVA

RG: 46241685, RJI: 170251493-18

Data De Nascimento: 30/12/1989

Filiação: pai ADEMIR DONIZETE DA SILVA, mãe MARIA APARECIDA COLOVATTI SILVA

Residência: R. FRANCISCO CASARI NOVO, 180, JD ALVORADA, R. FRANCISCO CASARI NOVO, Itapui-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.